

1528707-64.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528707-64.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528707-64.2021.8.26.0228, c. 1431/21

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2322666/2021 - 49º D.P. SAO MATEUS, 21633247 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2322666 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO DE BRITO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

FERNANDO DE BRITO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 26 de novembro de 2021, por volta das 11h30, na Rua Fortim Itapoa, nº 103, Iguatemi, São Paulo - SP, trazia, para fins de tráfico, 31 porções de cocaína, pesando 6,2g, 87 porções de maconha, pesando 267g, 48 porções de crack, pesando 18,6g, e 03 frascos de lança-perfume, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Em 06 de dezembro de 2021 houve a determinação para a notificação do réu e apresentação da defesa prévia (fls. 91/95).

O réu foi notificado (fls. 119) e ofertou defesa preliminar, arrolando as mesmas testemunhas da acusação (fls. 123). A denúncia foi recebida (fls. 124) e o réu devidamente citado (fls. 154).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo em seguida o réu interrogado. Não foram requeridas diligências pelas partes.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público reportou-se ao contido nos autos, pedindo a condenação do réu nos termos da denúncia. Com relação às penas, pediu a elevação da pena-base, o reconhecimento da reincidência e da confissão, não aplicação do redutor e a fixação do regime inicial fechado.

A Defesa requereu a absolvição por ilegalidade da abordagem policial.

Subsidiariamente, requereu a manutenção das penas no mínimo legal, a incidência da atenuante da confissão, detração e regime de acordo com o montante de pena.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é procedente.

Os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas, quando visualizaram o réu, que estava com uma bolsa tiracolo e mudou de direção ao perceber a presença da viatura, ingressando em outra via, onde foi abordado. Em revista pessoal, dentro da bolsa que ele carregava, encontraram porções fracionadas de diversas drogas (cocaína, maconha, crack e lança-perfume), bem como a quantia próxima de R\$ 100 (segundo o policial Renan) em notas trocadas. O réu confessou a prática delitiva. Não o conheciam anteriormente. Não sabem se ele reside nas proximidades. Ninguém interveio em favor dele. Com ele não havia qualquer petrecho para consumo de drogas e ele não parecia estar sob efeito delas.

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva.

Assim, é de se concluir pela existência da prática de tráfico pelo réu, o que se extrai da conjugação dos seguintes fatores: a variedade, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, que estavam em porções individuais, prontas para consumo; as circunstâncias da prisão em flagrante, com a consequente abordagem do réu em local conhecido como ponto de venda de drogas, a tentativa de fuga ao notar a presença da viatura e o fato das drogas terem sido localizadas na bolsa que estava em seu poder; a incompatibilidade entre a quantidade de droga e a situação financeira declarada pelo réu, que estaria desempregado; e a ausência de demonstração que as drogas destinavam-se para seu consumo próprio, tendo em conta a variedade de drogas e a quantidade de porções, além do fato de que não possuía qualquer apetrecho destinado ao uso dos entorpecentes. Em caso análogo já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"TESTEMUNHA - Tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Inexistência de razão concreta para suspeição - Relatos que merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral - Interpretação do artigo 202 do Código de Processo Penal - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Drogas apreendidas na residência da ré que não produziu qualquer prova de que não fossem de sua propriedade - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Casa conhecida como local de venda de entorpecentes, quantidade e acondicionamento da droga apreendida que nenhuma dúvida deixam a respeito da destinação comercial do produto - Recurso não provido." (Ap. Crim. nº 247.848-3 - São Paulo - 6ª Câm. Crim. de "Julho/98" - Rel. Debatin Cardoso - J. 13.08.98 - v.u).

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando o que disseram em sede policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. Neste sentido:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO

MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016)

Observo que as pequenas contradições havidas em seus depoimentos apenas denotam que prestaram declarações verdadeiras, sem que tenha havido prévio ajuste, sendo certo que as contradições havidas dizem respeito a pontos marginais e não essenciais à diligência.

Ademais, o próprio réu confessou o tráfico de drogas, o que se encontra em conformidade com os demais elementos de prova.

As substâncias entorpecentes apreendidas foram submetidas a exame pericial que comprovou seus efeitos tóxicos (fls. 132/135), também a corroborar o contido na denúncia.

Considera-se que a abordagem policial levada a cabo nestes autos seja regular e não esteja de qualquer forma viciada. Com efeito, os elementos concretamente descritos pelos policiais ouvidos indicam que havia fundada suspeita a ensejar a abordagem e a revista pessoal, nos exatos termos previstos pelo artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Ora, os policiais narraram que o local dos fatos é conhecido ponto de tráfico, disseram que avistaram o réu portando uma bolsa tiracolo, que ele demonstrou nervosismo ao avistar a guarnição policial e tentou dela se afastar, mudando a direção que seguia. Considera-se que tais elementos sejam suficientes para configurar a fundada suspeita legalmente prevista para dar ensejo à abordagem e consequente revista pessoal ao réu.

Forçosa, destarte, a condenação do réu nos termos acima referidos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, ante o seu mau antecedente (10ª VC, autos 0024776-02.2009, com extinção da pena pelo cumprimento em 18/12/2014 - fls. 141 e 149) e dada a natureza excepcionalmente nociva de parte dos entorpecentes (cocaína e crack), em diversas porções destinadas à venda, a revelar elevado e devastador efeito psicotrópico, autoriza-se a fixação da pena acima do mínimo legal, vez que tais circunstâncias excedem o desvalor inerente ao tipo, razão pela qual majoro a pena-base do réu em 1/5, ficando em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Anoto que não há qualquer ilegalidade no reconhecimento de tal condenação como mau antecedente, uma vez que o E. STF é pacífico no sentido de que inexistente ilegalidade no reconhecimento de condenação como mau antecedente, após decorrido o período depurador, por não haver qualquer limitação temporal estabelecida pelo legislador. Este o entendimento fixado por ocasião do julgamento do Tema 150, no RE 593818, com o seguinte enunciado: "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

Além disso, nota-se que a jurisprudência vem na linha do entendimento do juízo em relação à natureza da droga, confira-se: "A natureza nociva da substância entorpecente apreendida - cocaína - constitui fundamentação idônea a ensejar maior apenação na primeira etapa da dosimetria, pela desfavorabilidade das consequências do delito." (HC 141092/MS).

Na segunda fase, trata-se de réu reincidente (32ª VC, autos 0001155-49.2018, com trânsito em julgado para a defesa em 02/05/2018 - fls. 140), que confessou integralmente a prática delitiva. Esta magistrada adota o entendimento de que no concurso da agravante da reincidência e da atenuante da confissão deve prevalecer aquela, nos termos do artigo 67 do Código Penal. No entanto, o STJ, quando do julgamento do tema 585 em recurso repetitivo (RESP nº 1.341.370-MT) assentou o entendimento de que deve haver compensação de tais circunstâncias, motivo pelo qual

serão compensadas, permanecendo as penas no patamar visto acima. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei Antidrogas, tendo em vista que se trata de réu reincidente.

Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da questão. Com efeito, entende-se que seja aplicável regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque, a gravidade em concreto do delito em questão justifica o regime fechado, tendo em conta a quantidade e variedade dos entorpecentes, representando maior risco para a sociedade, pois causador de maior dependência química, sendo assim mais nocivo para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo legislador. Frise-se, por fim, que o delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Ademais, o réu estava em cumprimento de pena no regime aberto (fls. 141), demonstrando total indiferença aos fins da pena. Por tais motivos, somados ao fato do réu ser reincidente e que se encontrava em cumprimento de pena no regime aberto quando tornou a delinquir (fls. 81), não se justifica outro regime, que não o fechado, como inicial para cumprimento da pena. Neste sentido: STJ, RHC 37.637/SP, 5ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

As condições econômicas do réu são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu FERNANDO DE BRITO, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Frise-se, ainda, a sua reincidência e que tornou a delinquir em liberdade, aspectos que apenas ratificam que sua liberdade representa risco para a ordem pública. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Com o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida às fls. 124. Oficie-se para destruição da droga apreendidas.

P.R.I.

São Paulo, 27 de janeiro de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA